

1501350-31.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... se falar em insignificância penal com relação ao tráfico de drogas.

Neste sentido: "Prevalece nesta Corte o entendimento de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente" (EDcl no HC ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501350-31.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501350-31.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DE OLIVEIRA SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

THIAGO DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 13 de dezembro de 2021, por volta das 11h14min, na Rua Avelino Antônio de Campos, nº 10, Caetetuba, nesta cidade e Comarca de Atibaia, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, drogas, consistentes em 01 porção de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 7 gramas, bem como 20 porções de crack, com peso aproximado de 12 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelas proximidades do endereço acima mencionado, conhecido ponto de venda de drogas, momento no qual avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo um deles o ora réu - o qual entregava determinado objeto ao outro, posteriormente identificado como Carlos Clarindo dos Santos.

Os agentes públicos procederam à abordagem de ambos e, em poder do réu, no interior de uma pochete, localizaram vinte porções de crack, bem como uma pequena porção de maconha, além de R\$178,95.

Já com Carlos, os policiais encontraram quatro porções de crack, embaladas de forma idêntica àquelas que THIAGO trazia consigo.

Ao serem instados, Carlos admitiu que havia acabado de adquirir a droga apreendida, para consumo próprio, ao passo que o réu confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que pelas circunstâncias da prisão em flagrante, pela quantidade de droga, bem como pelo numerário apreendido, que as substâncias pertenciam ao réu e se destinavam ao comércio ilícito.

O flagrante foi convertido em preventiva às fls. 47/52.

O réu foi notificado (fls. 114) e apresentou defesa prévia (fls. 121/122), que foi afastada, sendo recebida a denúncia (fls. 129/132).

O réu foi citado (fls. 199).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e duas testemunhas arroladas pela defesa, tendo o Ministério Público desistido da oitiva da testemunha Carlos, o que foi homologado, sendo o réu interrogado ao final (fls. 207/208 e fls. 215/216).

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal porque provados os fatos narrados na denúncia (fls. 220/224).

A defesa requereu, preliminarmente, a realização de perícia toxicológica, argumentando que o réu é doente e usuário de drogas. No mérito, pugna pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos correlatos, do CPP, argumentando, em síntese, que não há prova cabal do tráfico ilícito de drogas; reitera a impugnação ao documento de fls. 77; postula, também, a aplicação do princípio da insignificância ou, ainda, a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; subsidiariamente, em caso de condenação, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação do regime aberto, e direito de recorrer em liberdade (fls. 230/235).

É o relatório.

Passo a decidir.

Por primeiro, afasto o pleito da defesa quanto à realização de perícia toxicológica, uma vez que, conforme já devidamente decidido e fundamentado durante a audiência, não há nos autos elementos que demonstrem que o réu é dependente químico ou incapaz de responder pelos seus atos, não tendo sido juntado qualquer documento ou produzida qualquer prova neste sentido, de modo que não há o mínimo indício necessário para a que seja deferida a realização da perícia pleiteada.

Ao mérito.

Neste, a ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), no boletim de ocorrência (fls. 11/13), no auto de exibição/apreensão (fls. 14/15), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 16), nas fotografias (fls. 37/38), nos laudos toxicológicos (fls. 101/103 e 104/106), e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada ao réu que, interrogado extrajudicialmente, permaneceu silente (fls. 09).

Em juízo, interrogado, optou por permanecer em silêncio. Questionado acerca de sua vida pregressa, disse que trabalhava como ajudante de pedreiro; estudou até o primeiro colegial; já foi processado anteriormente, por uso de drogas; às reperguntas da defesa, questionado há quanto tempo tem problemas com o uso de drogas, disse que desde seus dezessete anos de idade; questionado se já buscou tratamento alguma vez, disse que não; já cogitou, mas acabou não fazendo tratamento; questionado se se considera usuário de drogas, disse que sim; questionado se se considera doente pelo uso de drogas, disse que sim; questionado como está passando o período em que está preso, sem o uso de drogas, disse que por um lado, está sendo difícil, mas por outro, está sendo bom, pois está conseguindo deixar o vício, embora seja difícil; questionado se faz uso de alguma coisa para compensar a falta da droga, disse que só cigarro (fls. 215/216).

A testemunha comum Filipi Barbosa Bucciarelli, policial militar, ouvida às fls. 207/208, disse que estava em patrulhamento em moto, pelo município de Atibaia, no bairro Caetetuba, na Rua Avelino Antônio de Campos, local conhecido pelo tráfico de drogas, quando visualizou o réu passando algo para outro indivíduo que estava no

local e, de imediato, abordou ambos, tendo constatado que THIAGO havia passado quatro pedras de crack para o outro indivíduo; feita busca pessoal, foi encontrada com THIAGO uma pochete contendo vinte pedras de crack idênticas às que estavam na mão do outro indivíduo, além de R\$ 178,00; indagado, o réu admitiu que estava traficando, e que havia acabado de vender as drogas ao outro indivíduo, que também foi conduzido à Delegacia, juntamente com THIAGO; questionado se já conhecia o réu e o outro indivíduo de outras abordagens, disse que não; questionado se o local da abordagem é amplamente conhecido como ponto de venda de drogas, disse que sim; questionado se o réu confirmou que o dinheiro era oriundo da venda de drogas, disse que também; os entorpecentes e o dinheiro estavam juntos; às reperguntas da defesa, questionado qual foi a versão dada pelo indivíduo que foi pego junto com o réu, disse que ele disse que era morador de rua, e admitiu que estava comprando as pedras de crack de THIAGO; questionado se lembra do nome do outro indivíduo, disse que salvo engano, é Carlos; questionado quem seria o morador de rua, disse que THIAGO estava vendendo, e Carlos seria o morador de rua; questionado se havia mais pessoas no local, disse que não, apenas os dois indivíduos; questionado se o réu disse que estava com o padrasto e se estava trabalhando momentos antes, disse que ele não falou nada sobre isso no momento da abordagem; questionado qual era sua função na abordagem, disse que sua guarnição é composta por motocicletas, sendo que cada policial conduz uma motocicleta; assim como seu parceiro, pode andar na frente ou ao lado; questionado se havia algum oficial comandando a abordagem, disse que é muito difícil haver um oficial fiscalizando a abordagem, sendo que a viatura de quatro rodas foi chamada após a constatação do ilícito, e o sargento ou o oficial podem conversar com equipe no DP, mas é muito difícil haver um oficial fiscalizando a abordagem; questionado se foi feita a filmagem da abordagem, disse que as motocicletas, assim como a viatura de quatro rodas, não possuem esse sistema e, no interior, na região de Bragança Paulista, as equipes ainda não possuem a "bodycam"; questionado qual foi a reação do réu durante a abordagem, disse que o réu não concordou muito com a voz de prisão, tendo questionado se seria preso por causa daquilo, mas não resistiu, no entanto, para evitar uma possível fuga do réu, bem como para preservar a integridade do réu e da própria equipe, foi feito o uso de algemas.

A testemunha comum Gabriel Bueno, policial militar, ouvida às fls. 207/208, disse que estava em patrulhamento com motocicleta, pelo bairro Caetetuba quando, ao adentrar a via citada, visualizou um indivíduo passando algo para outro, tendo sido identificados, respectivamente, como THIAGO e Carlos; realizada a abordagem, foram localizadas, com Carlos, quatro pedras de crack, sendo que, com THIAGO, foram localizadas cerca de vinte pedras de crack, e dinheiro; indagado, Carlos informou que estava comprando a droga de THIAGO, que, por sua vez, admitiu que estava traficando, e que havia acabado de vender a droga a Carlos; questionado se as drogas que foram encontradas com Carlos estavam embaladas da mesma forma que as drogas encontradas com THIAGO, disse que da mesma forma, sim; não conhecia os indivíduos de outras abordagens; o local da abordagem é conhecido como ponto de venda de drogas; questionado se o réu admitiu que o dinheiro era oriundo da venda de drogas, disse que sim; às reperguntas da defesa, questionado se o réu não admitiu o crime no final da abordagem, disse que em todo momento, THIAGO admitiu o crime mas, no final da abordagem, ele não queria ser preso, como ninguém quer; o réu relutou em ser detido, mas em momento algum negou o crime; diante dos fatos, e tendo em vista o crime de prevaricação, não há como não efetuar a prisão de um indivíduo que acabou de praticar um crime e confessá-lo.

A testemunha de defesa Damião Pereira Filho, padrasto do réu, ouvido às fls. 207/208, disse que não presenciou a abordagem e não sabe nada sobre os fatos; às reperguntas da defesa, questionado sobre ter constado que estava com o réu instantes antes de ele ser preso, disse que não; questionado se trabalha com o réu, disse que não; quando foi morar com a mãe de THIAGO, ele estava morando junto; estava com a mãe do réu havia um ano e quatro meses, sendo que THIAGO estava morando consigo; questionado pelo juízo se trabalhavam juntos, disse que THIAGO trabalhou uns dias consigo, saiu e não retornou, tendo sido informado, posteriormente, que ele estava preso; questionado pelo juízo quanto tempo fazia que

não via o réu, disse que não lembra há quanto tempo ele está preso, mas fazia cerca de quinze dias desde que ele tinha sumido; questionado pela defesa se, na data dos fatos, o réu tinha trabalhado consigo, disse que ele havia trabalhado uma semana antes, mas depois ele saiu, e não teve mais notícia dele; questionado o que pode falar da idoneidade do réu, disse que é um "cara" bom, trabalhador, e não sabe porque aconteceu isso com ele, nem porque ele tomou essa atitude; sai cedo e só chega à noite, assim como a mãe do réu, sendo que trabalham; não sabe o que aconteceu com o réu; questionado se o réu já teve problemas com consumo de drogas, disse que sim; THIAGO já teve problemas com uso de drogas; o réu é uma pessoa boa, trabalhadora e inteligente, mas não sabe por que ele "aprontou" isso, ou se foi forjado; questionado se o réu já passou por algum tratamento de saúde por conta do uso de drogas, disse que não sabe; questionado o que a mãe do réu fala com relação a esse problema de saúde, disse que ela está passando dificuldades, sendo que ela está grávida, fica preocupada, começa a chorar, e quase todo dia a leva para o hospital; questionado se a mãe do réu já comentou alguma coisa com relação ao problema dele com as drogas, disse que ela sempre comenta sobre ele usar demais; o réu é trabalhador, mas começa a usar drogas, e a mente vai enfraquecendo cada vez mais; a mãe do réu fala que ele começou a usar drogas aos dezessete anos; às reperguntas da acusação, questionado se a mãe do réu tem outros filhos, disse que tem mais seis filhos; questionado quantos desses seis filhos também são usuários de drogas, disse que mais um; questionado pelo juízo se a mãe do réu tem sete filhos e está esperando o oitavo, disse que sim; questionado se dos oito filhos dela, dois usam drogas, disse que sim; questionado pela defesa se já ouviu alguém dizer que o réu integra ou integrou alguma organização criminoso, disse que não.

A testemunha de defesa Carlos Clarindo dos Santos, ouvida às fls. 215/216, disse que comprou o crack de THIAGO, sendo que o réu admitiu, ao policial, que tinha vendido a droga; não se recorda quantas pedras comprou; questionado se já tinha visto THIAGO no local outras vezes, disse que não; questionado sobre ter dito, na Delegacia, que já conhecia THIAGO do mesmo local, disse que "de vista", só de passagem, mas não o conhece; questionado se já tinha visto o réu no local outras vezes, disse que não frequentemente, pois não frequenta o local sempre; questionado se já tinha comprado drogas do réu em outras oportunidades, disse que não; questionado se essa foi a primeira vez, disse que "é"; às reperguntas da defesa, questionado, uma vez que falou que conhece o réu "de vista", em que situações o viu, disse que o viu na rua, quando estava passando; questionado pelo juízo se o viu na rua, mas não é amigo dele, disse que nada disso; questionado pela defesa se, durante a ocorrência, o réu estava acompanhando, disse que não; questionado se, no local, além de comprar, as pessoas costumam usar drogas, disse que não sabe, pois só passa no local quando vai comprar o que irá utilizar, e não faz uso no local; questionado se compra drogas nesse local há muito tempo, disse que bem mais de dois anos; questionado se, em todos esses anos, tinha se deparado com o réu antes, disse que duas ou três vezes; questionado se, nas outras vezes em que viu o réu, ele estava vendendo drogas, disse que não, pois o viu em outras situações, na padaria, ou em uma lanchonete; questionado se já ouviu falarem alguma coisa do réu, disse que não; questionado se sabe se o réu ostenta bens por onde passa, no bairro, disse que não sabe, pois apenas o encontrou na rua, e não sabe da vida particular dele. Assim, os fatos estão plenamente comprovados.

O réu, interrogado em fase policial e em juízo, optou por permanecer em silêncio. Os policiais narraram, em síntese, que estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto do tráfico de drogas, quando visualizaram o réu entregando algo para outro indivíduo e, ao realizarem a abordagem, constataram que o indivíduo, de nome Carlos, estava em posse de quatro porções de crack, que acabara de comprar de THIAGO que, por sua vez, levava consigo uma pochete contendo vinte porções de crack idênticas às que foram encontradas com Carlos, além de dinheiro. Disseram, também, que o réu, indagado, admitiu o tráfico, bem como a origem ilícita do dinheiro. Quanto aos policiais, há de se lembrar que seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais ou das forças de segurança, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que viriam a

Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, judiciais que sejam prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contra-senso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamasse à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Não. Inexistente qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de policiais, civis ou militares, de resto, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retirasse valor, "a priori", dos depoimentos policiais, pelo simples fato de terem sido emanados por pessoas revestidas de tal qualidade. Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência: "A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF-HC 70.237- Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94); "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimentos estes que, em Juízo, harmônicos entre si, sintonizaram-se com os depoimentos prestados extrajudicialmente, policiais que não conheciam o réu, e não tinham interesse maior na sua gratuita acusação.

A testemunha de defesa Damião, padrao do réu, disse, em síntese, que não presenciou a abordagem, e que o réu não tinha trabalhado consigo na data dos fatos, tendo relatado, ainda, que a mãe de THIAGO falou que ele usa drogas desde os dezessete anos.

Por fim, a testemunha de defesa Carlos disse que comprou a droga de THIAGO, sendo que o réu admitiu, aos policiais, no momento da abordagem, que realmente havia vendido os entorpecentes.

Assim, ao contrário do que alegou a defesa, em seus memoriais, verifica-se que o robusto conjunto probatório trazido aos autos é plenamente capaz de ensejar a condenação do réu, uma vez que os relatos dos policiais se mostraram firmes e coerentes, tendo sido narrado como se deu a abordagem, ocasião em que foram encontradas, com o réu, 20 porções de crack, embaladas individualmente, prontas para a venda, e uma porção de maconha, o que se confirmou pelas fotografias e pelo laudo juntados, além de R\$ 178,00, cuja origem lícita não foi comprovada, além do depoimento da testemunha Carlos, que narrou que comprou a droga do réu, estando claro que o réu estava, de fato, na traficância, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

Quanto à alegada insignificância, não pode ser acolhida, posto que a jurisprudência pátria entende que não há que se falar em insignificância penal com relação ao tráfico de drogas.

Neste sentido: "Prevalece nesta Corte o entendimento de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente" (EDcl no HC 463.656/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018).

O pleito da defesa de desclassificação do tráfico para o delito de uso de drogas também não pode ser acolhido, isto porque a negativa, por si só, é irrelevante e comum ao tráfico.

Neste sentido:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP101/498).

Por fim, observo que o tipo do art. 33 não faz menção a 'uso próprio'. Tal menção é feita no art. 28, ambos da Lei 11.343/06. Destarte, se o réu acusado de tráfico pretende que se aceite que a posse da droga era para uso próprio, com desclassificação para o art. 28, e consequente desfazimento da presunção de que se trata de traficante, terá que provar a alegada destinação. E esta prova cabe à defesa, não à acusação. Na hipótese, tal prova não foi feita, tendo o réu permanecido silente em solo policial e em juízo.

Assim, uma vez que o tráfico de drogas restou devidamente comprovado pelo robusto conjunto probatório trazido aos autos, não há que se falar em desclassificação, nem em absolvição.

Por fim, as alegações da defesa quanto ao documento de fls. 77 em nada alteram os fatos, que restaram amplamente comprovados, nos termos da fundamentação supra.

Assim, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu é reincidente, o que será analisado em fase própria.

Culpabilidade normal à espécie. Quanto à conduta social, nada a valorar. Quanto aos motivos do crime, nada capaz de ensejar modificação de pena. As consequências do crime são as normais ao tráfico. Não há que se falar em comportamento de vítimas. Quanto à natureza e quantidade do produto, verifica-se que o réu trazia consigo 20 porções de crack e uma de maconha, além das outras porções de crack que já tinha vendido a Carlos, conforme relatado pelos policiais.

O crack é um dos entorpecentes mais perigosos conhecidos, gerador dos efeitos mais nefastos em seus usuários. A alta taxa de mortalidade entre os consumidores e o absurdo poder viciante do entorpecente são motivos mais que suficientes para que seja, sua comercialização, exemplarmente repreendida (artigo 42, Lei 11.343/06). Sobre o tema, pronunciou-se Guilherme de Souza Nucci: "(...) não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal (...) A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que significa destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas 6ª ed. - São Paulo: RT 2012 v. 1 p. 287).

Assim, em razão da natureza, quantidade e grau de nocividade das drogas apreendidas, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso, portanto, sem renda.

Na segunda fase de dosimetria, há a agravante do art. 61, II, j, do CP, já que os fatos foram praticados durante estado de calamidade, decretado em razão da pandemia Covid-19, bem como a agravante da reincidência, conforme se verifica às fls. 42/43 (proc. 4278-41.2016 - tráfico).

Observo que agravantes ou atenuantes não são circunstâncias elementares do crime, motivo pelo qual é prescindível que elas constem da denúncia (art. 385, CPP). Não há atenuantes.

Assim, agravo a pena do réu, que passa a 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 888 dias-multa.

Na última fase, não há causas de aumento de pena.

Afasto a incidência do benefício do parágrafo 4º, porque o réu é reincidente específico, não preenchendo, portanto, os requisitos legais, dedicando-se às atividades criminosas.

Incabível, também, a substituição do art. 44, bem como a suspensão do art. 77, ambos do Código Penal, porque, repito, se trata de réu reincidente específico, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para a concessão dos benefícios. O regime inicial para cumprimento da pena será o fechado.

O tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização – sobre o óbvio, diga-se –, tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado. Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática – a tão altos custos – permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz, inclusive, de ensejar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável prática.

Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto final e, principalmente, porque alguém o vende – eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente – geralmente identificado como o “pequeno traficante” – deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio “varejista” das drogas, fomentando o consumo e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminosa ligada ao narcotráfico – prática delitiva que domina a maior parte dos debates sobre segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante – a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343/06 – pelo gerente de “boca” ou por associados a organizações criminosas – pessoas a quem a Lei trata de maneira especial e mais severa.

O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“(…) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição

automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressaltada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas. Portanto, acolho a pretensão do representante do Ministério Público e fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que se trata do regime compatível com a conduta do acusado. Cumpre ressaltar ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade. Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. Devo reconhecer que tenho sido voto vencido junto a meus pares, a cujos posicionamentos me curvo com a humildade esperada, e por isso mesmo, eventualmente, sou reconhecido como extremamente rigoroso, entretanto, não o faço como castigo, o que seria de todo despropositado e bem acarretaria o desvirtuamento da finalidade da pena. É imperativo ressaltar

também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante. (...)” (APL TJ-SP 0027320-18.2012.8.26.0224; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 18/01/2017; Julgamento: 14 de Dezembro de 2016; Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro).

Salutar a fundamentação, que reduz a termo o espírito buscado pela construção normativa do Legislador. É razão mais que suficiente para que se entenda que o praticante do tráfico de drogas deve permanecer afastado do convívio em sociedade, especialmente considerando, repito, que se trata de réu reincidente específico. Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno THIAGO DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e multa de 888 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

DECRETO a perda do dinheiro apreendido com o réu, dando-se a devida destinação. O réu está preso e assim deverá permanecer, já que foi preso em flagrante e permaneceu recolhido por todo o processo, não sendo razoável que, agora que foi condenado, seja colocado em liberdade, ainda mais diante do fato de ter praticado conduta de extrema gravidade, nos termos acima fundamentados. A prática exige punição exemplar. Ademais, não há segurança ao juízo de que o réu, uma vez em liberdade, não acabe voltando a praticar o delito que culminou com sua prisão, seja para saldar eventual dívida que ostente com o tráfico, em razão da apreensão das drogas, seja para garantir seu próprio sustento, especialmente considerando que se trata de réu reincidente específico. Além disto, permanecem íntegros os motivos que ensejaram a conversão de sua prisão em preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Suspensa, entretanto, a condenação, caso o réu seja beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I. e C.

Atibaia, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA